

1500239-09.2021.8.26.0546

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO HENRIQUE ADUAN CORREA

Comarca: Artur Nogueira

Foro: Foro de Artur Nogueira

Vara: 1ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... em 19/04/2018, DJe 30/04/2018)

"Tráfico de Drogas - Recurso ministerial visando a condenação do apelado pelo tráfico de drogas - Possibilidade - Nulidade da prisão realizada por guardas municipais afastada - Agentes públicos que, como qualquer outro cidadão, têm o poder de prender quem quer que se encontre em flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP - Prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Artur Nogueira

Foro de Artur Nogueira

Vara Única

Rua 13 de Maio, 140, Artur Nogueira - SP - cep 13160-170

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500239-09.2021.8.26.0546 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500239-09.2021.8.26.0546

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCELO MARTINS LANA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO HENRIQUE ADUAN CORREA

Vistos.

MARCELO MARTINS LAMA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pelos fatos melhor descritos na exordial de fls. 02/03.

O acusado foi notificado (fls. 112) e, por meio de seu defensor, apresentou defesa preliminar (fls. 118/120).

O recebimento da denúncia ocorreu em 28/10/2021 (fls. 133) e o réu foi citado (fls. 139).

Durante a instrução foram inquiridas três testemunhas, procedendo-se, ao final, ao interrogatório do acusado.

Em sede de alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do réu.

Já a Defesa do acusado suscitou nulidades processuais e, no mérito, requereu a absolvição.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade processual aventada pela Defesa técnica.

Com efeito, a prisão em flagrante efetuada pelos guardas municipais não constitui ato ilegal, estando em conformidade com o que prevê o artigo 301 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS PARA EFETUAR PRISÃO EM FLAGRANTE. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexistente óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. No presente caso, a segregação cautelar foi decretada pelo Tribunal estadual, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada (i) pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto a ré já possui condenação por tráfico de drogas e (ii) pela quantidade de entorpecente apreendido (147,23g de maconha, 21, 51g de crack e 104,82g de cocaína). Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Precedentes. 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Recurso ordinário improvido". (RHC 94.061/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018)

"Tráfico de Drogas – Recurso ministerial visando a condenação do apelado pelo tráfico de drogas – Possibilidade – Nulidade da prisão realizada por guardas municipais afastada – Agentes públicos que, como qualquer outro cidadão, têm o poder de prender quem quer que se encontre em flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP – Prova segura – Tráfico de drogas demonstrado – Condenação necessária – Dosimetria – Aumento da pena-base em função dos píssimos antecedentes do acusado – Privilégio incabível ante a significativa quantidade e variedade de drogas – Regime semiaberto – Recurso provido". (TJSP; Apelação Criminal 1502947-96.2020.8.26.0536; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/09/2021; Data de Registro: 21/09/2021)

Importa considerar, ainda, que eventuais irregularidades ou ilegalidades da fase extrajudicial da persecução penal, momento da persecução penal em que ainda não se estabeleceu a relação jurídica processual, não têm o condão de contaminar o processo.

Não bastasse isso, tem-se que o art. 5º, incisos IV, XIV, XVI, e parágrafo único, da Lei nº 13.022/2014, autoriza a atuação da Guarda Municipal diante de situações envolvendo a prática de infrações penais, especialmente naquelas que envolvem hipótese de flagrante delito, razão pela qual nenhuma nulidade há a ser

reconhecida.

Destaco, ainda, que, no caso em tela, havia elementos concretos que permitiam evidenciar a ocorrência de flagrante delito, tanto assim que os guardas apenas ingressaram na residência do réu após o verem dispensando ao solo um embrulho, poucos minutos antes, em cujo interior havia drogas.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade restou demonstrada por meio do laudo químico-toxicológico de fls. 78/80 que atestou pericialmente ser cocaína a substância trazida e tida em depósito pelo acusado, estando relacionada na Portaria SVS/MS 344, de 12 de maio de 1998. Destaco que o laudo pericial de fls. 78/80 faz menção exatamente aos mesmos números de lacres daqueles indicados no auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, não havendo que se falar em quebra da cadeia de custódia, especialmente porque o número de porções apreendidas é a mesma, a natureza da droga é a mesma (cocaína) e não há dúvidas de que as substâncias encontradas pelos guardas são as mesmas que foram objeto da perícia.

A autoria delitiva, de igual sorte, é indubitável.

O réu, em solo policial, negou a propriedade das porções de cocaína encontradas pelos guardas na via pública e em sua casa. Disse ser apenas usuário de maconha. Em juízo, alterou a versão dos fatos, tendo dito que as drogas eram para seu consumo, tendo pago R\$ 150,00 pelas porções.

Ocorre que a versão por ele apresentada não encontra respaldo no conjunto probatório amealhado nos autos.

Com efeito, os guardas municipais responsáveis por sua prisão asseveraram que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram o réu, já conhecido dos meios policiais pela prática do crime de tráfico de drogas. O acusado, ao perceber a presença da viatura, dispensou algo debaixo de um ônibus que estava estacionado. Em revista pessoal, os guardas lograram êxito em localizar com o acusado a quantia de R\$ 70,00 em notas diversas. Afirmaram, ainda, que dentro do saco branco lançado pelo réu havia oito porções de cocaína. Posteriormente, deslocaram-se até a residência do acusado, oportunidade em que localizaram, no interior de seu guarda-roupas, mais 6 porções de cocaína idênticas àquelas que o réu havia dispensado, bem como a quantia de R\$ 152,00 em notas de diversos valores. A testemunha Edna Souza da Silva disse que não presenciou os fatos, tendo dito que o réu é pessoa honesta e trabalhadora. Nunca soube de nenhum fato que desabonasse o comportamento do acusado.

Da análise das provas coligidas aos autos permite-se concluir, com absoluta certeza, que o acusado efetivamente praticou o crime de tráfico de entorpecentes que lhe fora imputado na exordial acusatória.

Isso porque os guardas ouvidos em juízo foram taxativos ao mencionar que o réu, na data dos fatos, dispensou sob um caminhão um saco branco contendo 08 (oito) porções de cocaína assim que notou a presença da viatura, conduta absolutamente incompatível com quem se diz inocente.

Em sua casa, por sua vez, foram encontradas outras 6 porções de cocaína embaladas da mesma forma que aquelas trazidas pelo acusado, o qual a cada momento forneceu uma versão sobre as substâncias, ora negando sua propriedade, ora dizendo que as consumiria, comportamento absolutamente diverso daquele adotado pelos guardas responsáveis pela prisão, os quais sempre apresentaram sua versão de forma firme, enfática e coerente.

Não bastassem tais elementos de prova, deve-se destacar que o acusado – pessoa que alegou auferir um salário mínimo por mês à época dos fatos e que era conhecida dos meios policiais por envolvimento no tráfico – foi surpreendido portando consigo R\$ 70,00 em espécie, em notas de diversos valores, e guardando em sua residência a quantia de R\$ 152,00, de origem lícita não comprovada, sendo fantasioso se imaginar que alguém que auferia pouco mais de mil reais por mês tenha conseguido adquirir, em uma única ocasião, R\$ 150,00 em drogas e tivesse à sua pronta disposição mais R\$ 222,00 em espécie.

A piorar ainda mais a situação do réu, recorro que em seu celular foram localizadas inúmeras fotografias alusivas a entorpecentes e a dinheiro em espécie (conforme laudo pericial de fls. 162/170), estando tudo a comprovar a procedência da acusação

feita pelo Parquet.

Reitero que, no caso em tela, não há razão para se afastar a credibilidade dos depoimentos prestados pelos guardas, especialmente por não se vislumbrar qualquer razão que justificasse eventual intenção destes em prejudicar injustamente o acusado, o qual não apontou qualquer circunstância apta a abalar a fé depositada no relato dos agentes que o detiveram.

Assim, estando verificadas a materialidade e autoria delitivas, a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas é medida de rigor.

Superadas tais questões, resta apreciar o cabimento da incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

No caso em apreço, mostra-se inviável seu reconhecimento, haja vista se tratar de réu reincidente e portador de maus antecedentes (conforme certidão de fls. 96/99).

Dessa forma, passo à fixação da pena corporal a ser aplicada ao acusado, com observância do sistema trifásico adotado pelo Código Penal (artigo 68).

Na primeira fase, em respeito ao que determinam os artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, reputo desfavorável a circunstância relativa à natureza da substância entorpecente trazida e tida em depósito pelo réu (cocaína), que é das mais prejudiciais à saúde humana, bem como o fato de o acusado possuir condenação criminal pretérita hábil a configurar maus antecedentes (certidão de fls. 96/99), razão pela qual elevo a pena-base em 1/5 (um sexto), fixando-a em 6 anos de reclusão, e 600 dias-multa, cada qual no mínimo legal.

Na segunda fase incide a circunstância legal agravante da reincidência (certidão de fl. 96/99), devendo a pena anteriormente fixada ser agravada em 1/6, razão pela qual fixo a reprimenda provisória em 7 anos de reclusão, e 700 dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de minorantes e majorantes.

Registro que o fato de a reincidência do réu ter sido utilizada para agravar sua pena e, também, para impedir a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, não implica bis in idem.

Isso porque, conforme entendimento do qual compartilho, na segunda fase da aplicação da pena a reincidência é considerada para a finalidade de aumentar a pena a ser imposta ao agente, enquanto que, na terceira fase, a reincidência é considerada como forma de se impedir que o agente que não seja o traficante pequeno e eventual seja beneficiado com dispositivo legal idealizado para os indivíduos que ostentem bons antecedentes e passado criminal incólume.

Nesse sentido:

"TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade - Depoimentos de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Ausência de dúvida que justifica o édito - Impossibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 - Condenação mantida - Pena bem dosada - Réu portador de maus antecedentes e reincidente - Aumentos justificados - Bis in idem não verificado - Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas - Regime fechado que deve ser mantido - Recursos improvidos (voto n. 39223)".
(TJSP; Apelação Criminal 0052211-67.2017.8.26.0050; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/04/2019; Data de Registro: 02/04/2019)

Dada a falta de elementos probatórios acerca da situação econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do montante do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, haja vista que o quantum da pena imposta, aliado à presença da circunstância agravante da reincidência, recomendam referido regime como o único cabível, conforme prevê o artigo 33, §§ 2º e 3º, c/c art. 59, ambos do CP.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em virtude da quantidade de pena imposta.

Inviável, pelo mesmo motivo, a concessão do sursis.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu MARCELO

MARTINS LANA, qualificado nos autos, à pena corporal de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser atualizado em sede de execução, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, eis que não há nos autos qualquer informação acerca do comportamento carcerário dos acusados no período em que estiveram presos provisoriamente. De fato, ofende o princípio constitucional da isonomia, insculpido no artigo 5º, da CF, exigir-se do condenado definitivo a comprovação de que possui bom comportamento carcerário para que possa progredir de regime, enquanto que ao sentenciado provisório permite-se a progressão sem qualquer demonstração de sua conduta durante o período em que permaneceu custodiado. Assim, com o fito de evitar tal distorção, e fazendo-se uma interpretação sistêmica do ordenamento jurídico (artigo 112 da LEP), entendo que a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do CPP, fica condicionada à comprovação nos autos acerca do comportamento do acusado no estabelecimento prisional onde permaneceu detido. Ausentes documentos que atestem tal situação, não seria mesmo o caso de se progredir os réus de regime fixado nesta sentença.

Indefiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade, eis que subsistem os motivos que ensejaram a decretação de sua custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal).

Ad cautelam, expeça-se mandado de prisão e recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova, que deverá ser destruída após o trânsito em julgado.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63 da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder da ré (dinheiro) em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD), à Secretaria Nacional Antidrogas e à instituição financeira competente, para as providências cabíveis.

Transitada esta em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ), com a posterior expedição da respectiva Guia de Recolhimento.

Custas na forma da lei, cuja exigibilidade fica suspensa.

Publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Artur Nogueira, 28 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA